

COUP DE REGLE MINISTERIEL EN MATIERE DE CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES MINIERES EN RDC !

Patrick De Wolf, Guélord Mosau Mbombo, Don De Dieu Louis Nyembo, Dodi Kikunda,
Yannick Alenge, Harold Wouters
(DALDEWOLF)

Table des matières

INTRODUCTION	1
I. LA PARTICIPATION DES NATIONAUX CONGOLAIS ET DES TRAVAILLEURS (5 % + 5 %)	3
II. LA PARTICIPATION DES SALARIES (5 %) AU CAPITAL – COMMENT PROCEDER EN PRATIQUE ? 6	
1. Le véhicule : la société coopérative des travailleurs, un « trust » sans trust	7
2. L'objection centrale : la détention par une personne morale interposée satisfait-elle l'article 71 bis ?	8
3. Le financement : la gratuité organisée par l'AUSCGIE plutôt que l'endettement des salariés	10
4. La valorisation : une catégorie d'actions de préférence « salariés » (art. 778-1 et suiv. AUSCGIE)	11
III. L'ACCES DES PERSONNES PHYSIQUES CONGOLAISES (5 %) AU CAPITAL – COMMENT PROCEDER EN PRATIQUE ?	12
1. La décote objectivée par les actions de préférence (« <i>sweet equity</i> »)	12
2. L'entrée progressive par valeurs mobilières composées (art. 822 et suiv. AUSCGIE)	13
3. Le démembrement temporaire de propriété (art. 128 AUSCGIE)	13
4. La syndication verrouillée : une SAS d'investisseurs à « congolité » statutaire	13
5. La non-dilution organisée statutairement	14
IV. CONCLUSION	15

INTRODUCTION

1.

La réforme du droit minier opérée par la Loi n° 18/001 du 9 mars 2018 a profondément redéfini les règles de structuration financière et de gouvernance des entreprises du secteur extractif. Outre la cession à titre gratuit à l'État de 10 % du capital social, non diluables, lors de l'octroi du permis d'exploitation (article 71, litera d, du Code minier), elle impose la participation de

personnes physiques de nationalité congolaise à hauteur d'au moins 10 % du capital, dont 5 % au profit des travailleurs de l'entreprise (article 71 bis du Code minier et article 144 bis du Règlement minier). Ces règles étaient rarement appliquées par les sociétés minières¹.

2.

Par une note circulaire du 30 janvier 2026, le Ministre des Mines a rappelé ces exigences - singulièrement le volet des 5 % réservés aux travailleurs - et a enjoint aux sociétés minières d'établir la preuve juridique de leur conformité au plus tard le 31 juillet 2026. Cette échéance, dont la portée exacte est mesurée ci-après (point I), place la structuration du capital social au premier rang des priorités de conformité du secteur minier.

3.

La présente analyse vise à (ré)examiner ces règles et à poser les jalons méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre de l'actionnariat des salariés et des investisseurs privés personnes physiques congolaises au sein des sociétés minières.

Contrairement à une idée répandue, le droit OHADA n'est pas démunie face à ces exigences : s'il ne propose aucun véhicule d'actionnariat salarié « clé en main », il offre des instruments précis - attribution gratuite d'actions, rachat par la société de ses propres titres en vue de leur attribution aux salariés, actions de préférence, société coopérative à capital variable, indivision organisée, démembrement de propriété - dont la combinaison permet de répondre à chacune des difficultés que soulève la pratique. Ces difficultés seront prises de face : l'indisponibilité du trust en droit congolais, qui condamne les schémas de portage inspirés des modèles anglo-saxons ; la question, centrale, de la conformité d'une détention par véhicule interposé au prescrit du Code minier, qui réserve la participation à des personnes physiques de nationalité congolaise ; l'incapacité financière des travailleurs et des investisseurs congolais à acquérir directement des titres dans des projets miniers fortement valorisés ; et le risque de blocage technique et de gouvernance qu'entraînerait l'inscription individuelle de centaines de salariés comme actionnaires. Pour chacun de ces écueils, des mécanismes opérationnels de mise en œuvre des cessions en faveur des salariés et des investisseurs privés congolais sont proposés, dans la perspective de l'échéance administrative du 31 juillet 2026.

¹ Selon les informations rapportées par Reuters à la mi-juillet 2026, aucun des principaux producteurs actifs en RDC - notamment Glencore, Ivanhoe Mines, CMOC et Huayou Cobalt - n'avait encore procédé au transfert de titres requis, plusieurs d'entre eux ayant sollicité, en vain, un report de l'échéance.

I. LA PARTICIPATION DES NATIONAUX CONGOLAIS ET DES TRAVAILLEURS (5 % + 5 %)

4.

Introduit par l'article 71 bis du Code minier, ce dispositif exige la participation de personnes physiques de nationalité congolaise à la constitution du capital social des sociétés minières, à hauteur d'au moins 10 %. Il s'agit donc d'un plancher, non d'une quotité fixe. L'article 144 bis du Règlement minier en précise la clé de répartition duale : 5 % au profit d'un ou de plusieurs investisseurs privés de nationalité congolaise, et 5 % au profit des travailleurs congolais de l'entreprise minière. Le même texte déclare libre la cession de ces parts ou actions, en l'assortissant d'un droit de préemption destiné à préserver la quotité congolaise.

La lettre de l'article 144 bis ménage au demeurant une marge d'interprétation qui n'a pas échappé à la doctrine : en énonçant que les parts réservées « peuvent être acquises de la manière suivante », le texte laisse ouverte la question de savoir si la clé de répartition duale est impérative ou simplement indicative - auquel cas les 10 % pourraient être ventilés autrement entre investisseurs privés et travailleurs congolais². Sans qu'il soit nécessaire de trancher ici ce débat, la prudence commande de documenter la conformité sur la base de la répartition duale, tout en gardant à l'esprit la marge de structuration supplémentaire que cette ambiguïté pourrait offrir dans des configurations atypiques.

Le champ d'application de cette règle doit également être clairement défini. L'article 71 bis figure dans le chapitre du Code minier consacré à l'exploitation et la participation qu'il impose constitue une condition d'octroi du permis d'exploitation. Il faut donc considérer que cette obligation ne s'applique qu'aux sociétés minières qui exploitent une mine ou demandent un permis d'exploitation, et non aux titulaires d'un simple permis de recherche³. Pour être complet, on relèvera que les entités de traitement et de transformation opérant sans titre minier sont soumises à une exigence distincte, plus stricte encore – l'obligation de réserver

² V. Mbombo Mudiangombe, « L'indigénisation du capital social dans le secteur minier congolais : entre obligation de participation des salariés et défis d'effectivité des articles 71 bis du Code et 144 bis du Règlement minier », in *LegalRDC*, 30 juin 2026, qui consacre à cette ambiguïté une analyse herméneutique approfondie. Il est renvoyé, plus généralement, à l'abondante bibliographie doctrinale mobilisée par cette étude (notamment C. Mulungu Nachinda, *Code minier commenté et annoté*, Academia ; du même auteur, *Droit minier congolais : de la théorie à la pratique*, Academia-L'Harmattan, 2022 ; G. SAKATA M. TAWAB, *Code minier expliqué*, Academia, 2022 ; E. L. Owenga Odinga, *Les innovations apportées par la révision du Code minier : commentaire et considérations critiques*, éd. PPDC).

³ En ce sens, E. Kapita Akatshi et D. Nkanga Amba, « La participation des congolais personnes physiques au capital social des sociétés minières d'exploitation : entre exigence légale et contrainte pratique », *LegalRDC*, 23 juin 2026.

50 % de leur capital social à des personnes de nationalité congolaise -, qui excède le périmètre de la présente analyse⁴.

Contrairement à la participation étatique, que le Code minier déclare expressément cédée « libre de toutes charges », les textes sont muets sur le caractère gratuit ou onéreux de cette participation citoyenne. La doctrine dominante en déduit, a contrario, qu'elle s'acquiert à titre onéreux, selon le droit commun des cessions et souscriptions de titres de l'Acte uniforme OHADA. Ce silence est toutefois lourd de conséquences pratiques : ni la loi ni le règlement ne précisent qui doit supporter le coût de l'acquisition, selon quelles modalités de financement, ni à quel moment la participation doit être constituée pour les sociétés déjà en phase d'exploitation - autant de lacunes que le décret d'application annoncé devrait combler et qui, dans l'intervalle, laissent aux opérateurs une réelle marge de structuration (voir points II et III).

L'ampleur de la contrainte financière qui en résulte se mesure à l'aune de l'article 71, littéra b, du Code minier, qui impose que le capital social des sociétés d'exploitation représente au moins 40 % du coût total du projet. Pour un projet minier évalué à 800 millions USD, le capital social minimal s'élève ainsi à 320 millions USD : la quotité congolaise de 10 % représenterait 32 millions USD — et les 5 % des travailleurs, 16 millions USD —, montants hors de portée d'une acquisition directement financée par les bénéficiaires. C'est précisément cette barrière financière que les mécanismes exposés aux points II et III permettent de lever sans dénaturer l'économie des projets.

5.

Bien que cette disposition soit en vigueur depuis 2018, l'autorité de tutelle a considérablement intensifié sa politique de contrôle au début de l'année 2026.

Par une note circulaire du 30 janvier 2026 (Réf. : N°CAB.MIN/MINES/JPK/JMT/LKW/00306/2025)⁵, le Ministre des Mines a rappelé aux sociétés minières leur obligation de céder aux travailleurs congolais une participation équivalente à 5 % de leur capital social, sur le fondement de l'article 71 bis du Code minier et de l'article 144 bis du Règlement minier, et les a invitées à déposer à son cabinet, au plus tard le 31 juillet 2026, la preuve juridique de leur conformité : statuts actualisés, pactes d'actionnaires, registres des titres et tout autre

⁴ Cette exigence, distincte de celle de l'article 71 bis, a été rappelée dans le cadre des concertations de juillet 2026 entre le Gouvernement et le secteur minier (voy. not. Radio Okapi, 22 juillet 2026 ; Forêts du Congo, 23 juillet 2026).

⁵ Note circulaire non publiée au Journal officiel ; son contenu a été rendu public début février 2026 et rapporté par la presse spécialisée (not. Actualite.cd, 8 février 2026 ; Mines.cd et 7sur7.cd, 9 février 2026).

document probant établi conformément au droit congolais et aux Actes uniformes de l'OHADA.

La portée de cette échéance doit être exactement mesurée. Elle ne figure dans aucun texte légal ou réglementaire : l'obligation de participation existe depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2018, de sorte que le délai accordé ne constitue pas un report de l'obligation, mais un calendrier administratif de contrôle de son exécution. Inversement, une circulaire ministérielle est dépourvue de valeur normative propre : elle ne peut ni ajouter à la loi, ni fonder à elle seule une sanction. Toute mesure de contrainte - sanction administrative ou déchéance - devrait ainsi reposer sur les dispositions du Code minier lui-même, dont l'application à ce manquement particulier prêterait à discussion. La prudence commande néanmoins aux opérateurs de ne pas spéculer sur cette fragilité : les demandes de report portées par la profession ont, à ce jour, été écartées, et la détermination affichée de l'autorité de tutelle laisse présager un contrôle effectif dès l'expiration du délai. Cette détermination s'est encore confirmée le 21 juillet 2026 : à l'issue d'une concertation réunissant le Gouvernement et les représentants du secteur minier autour du projet de décret d'application de l'article 71 bis, les parties se sont accordées sur la signature du texte, sous réserve d'ajustements techniques confiés à un comité ad hoc, et l'échéance du 31 juillet a été expressément maintenue⁶.

6.

Le risque juridique peut être identifié avec précision. En amont, la participation congolaise est une condition d'obtention du permis d'exploitation. Si cette condition n'est pas remplie, le Cadastre minier (CAMI) pourrait rendre un avis défavorable et le permis pourrait ne pas être délivré. Il s'agit du principal risque pour les projets en développement⁷.

En aval, si un permis était accordé sans respecter cette exigence, l'arrêté ministériel qui l'a délivré pourrait être annulé pour illégalité sur la base de l'article 48 ter, alinéa 3, du Code minier.

En revanche, pour les sociétés qui sont déjà en phase d'exploitation, le Code minier ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non-respect de cette obligation. Cela confirme la fragilité juridique de toute mesure de contrainte qui serait prise après l'expiration du délai. Pour autant, les opérateurs ne sauraient considérer cette absence de sanction comme une garantie leur permettant de ne pas se conformer à la loi.

⁶ Radio Okapi, « Participation congolaise aux capitaux des sociétés minières : le Gouvernement accélère le processus », 22 juillet 2026 ; dans le même sens, Forêts du Congo, « Capital des sociétés minières : la RDC impose la part congolaise, malgré les réticences de l'industrie », 23 juillet 2026.

⁷ Sur le contrôle d'éligibilité opéré par le Cadastre minier et la sanction de l'avis cadastral défavorable, voy. E. Kapita Akatshi et D. Nkanga Amba, op. cit.

7.

Cet ultimatum s'inscrit dans une politique transversale de promotion du contenu local (local content) menée de front avec d'autres secteurs stratégiques, notamment les télécommunications, où l'application de l'article 40 de la Loi n° 20/017 (exigeant également une quote-part de 5 % pour les employés des entreprises des télécoms) a été réaffirmée lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 janvier 2026.

II. LA PARTICIPATION DES SALARIES (5 %) AU CAPITAL – COMMENT PROCEDER EN PRATIQUE ?

8.

L'exécution de l'obligation légale de cession de 5 % du capital social aux salariés place les sociétés minières au cœur d'une complexité opérationnelle réelle. Contrairement à une idée répandue, le droit OHADA n'est toutefois pas démuné : si l'AUSCGIE ne propose aucun véhicule d'actionnariat salarié « clé en main », il fournit des solutions précises - attribution gratuite d'actions (art. 626-1 et suivants), rachat par la société de ses propres actions en vue de leur attribution aux salariés (art. 640), actions de préférence (art. 778-1 et suivants), liberté statutaire de la SAS (art. 853-1 et suivants) - que complète, pour le véhicule collectif, l'Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives. L'ingénierie ne consiste donc pas à importer des mécanismes étrangers, mais à combiner des instruments qui existent déjà en droit positif.

9.

Un préalable s'impose : écarter le « trust de salariés » parfois évoqué dans le secteur. La fiducie-gestion n'existe ni en droit OHADA — l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ne connaît que le transfert fiduciaire d'une somme d'argent (articles 87 à 91) - ni en droit congolais, et la RDC n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance⁸. Un trust de droit étranger détenant les 5 % serait d'une opposabilité incertaine devant le juge congolais et heurterait l'exigence d'une détention par des personnes physiques de nationalité congolaise. La preuve de conformité attendue pour le 31 juillet 2026 doit donc reposer sur des véhicules et instruments de droit OHADA.

Quatre questions sont dès lors à traiter successivement : le choix du véhicule, sa conformité au prescrit du Code minier, le financement et la valorisation.

⁸ Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Aucun État africain ne figure parmi les États contractants.

1. Le véhicule : la société coopérative des travailleurs, un « trust » sans trust

10.

L'intégration directe de centaines de salariés dans le registre des titres nominatifs paralyserait la gestion de la société (votes en assemblée, formalités lors des départs de personnel ou des successions). Plutôt que d'inventer une entité *sui generis* au cadre juridique incertain, la société coopérative régie par l'Acte uniforme du 15 décembre 2010 offre un véhicule de portage collectif dont les caractéristiques épousent exactement les besoins de l'actionnariat salarié :

- *Capital variable (article 52)* : les entrées et sorties de coopérateurs s'opèrent sans modification statutaire ; les mouvements de personnel - recrutements, départs, décès — se dénouent par simple souscription ou remboursement de parts (article 11), là où une société de portage classique exigerait des cessions en cascade ;
- *Lien commun (article 8)* : la qualité de membre est statutairement réservée aux travailleurs congolais de l'entreprise ; les parts sont nominatives, non négociables et cessibles dans les seules conditions fixées par les statuts (articles 45 et 49) - l'anti-spéculation et la logique de sortie (*good/bad leaver* : remboursement statutaire au départ, exclusion pour faute) sont inscrites dans la loi et les statuts, non dans un simple pacte ;
- *Gouvernance démocratique* : un membre, une voix ; sous la forme de coopérative avec conseil d'administration (COOP-CA, quinze membres au minimum, article 267), le conseil peut réunir paritairement représentants élus des travailleurs et représentants de la direction, la coopérative détenant les 5 % de manière unique et globale et s'exprimant d'une seule voix aux assemblées de la société minière ;
- *Conformité anticipée* : la détention collective par voie coopérative correspond aux orientations annoncées du projet de décret d'application de l'article 71 bis, ce qui réduit le risque d'une restructuration ultérieure du schéma retenu.

11.

En variante, une SAS de portage demeure concevable, à condition d'en verrouiller les statuts : inaliénabilité des actions pour une durée maximale de dix ans (article 853-17), agrément et préemption sur toute cession, même entre associés (article 853-18), exclusion avec cession forcée et suspension des droits non pécuniaires (article 853-19), toute cession intervenue en violation de ces clauses étant nulle (article 853-19-1) et le prix, à défaut d'accord, fixé à dire d'expert (article 853-21). Le régime de départ cesse ainsi d'être purement contractuel pour devenir statutaire et opposable à tous.

2. L'objection centrale : la détention par une personne morale interposée satisfait-elle l'article 71 bis ?

12.

L'interposition d'une société coopérative - comme de tout véhicule doté de la personnalité juridique - soulève une objection qu'il faut prendre de face, car elle conditionne la validité de l'ensemble du schéma. L'article 71 bis exige que des « personnes physiques de nationalité congolaise » détiennent au moins 10 % du capital social. Or la société coopérative est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation : une fois les 5 % inscrits à son nom dans le registre des titres nominatifs, l'actionnaire de la société minière est, formellement, une personne morale. Une lecture littérale pourrait donc conduire l'administration des mines à considérer que le prescrit légal n'est pas satisfait, l'écran de la personnalité morale n'étant pas une fiction que l'interprète lève à sa guise.

Cette lecture formaliste ne résiste toutefois pas à l'analyse, pour quatre raisons convergentes.

En premier lieu, le texte n'exige nulle part une détention « directe » : lorsqu'un législateur entend l'imposer, il le précise - comme le font classiquement les législations de contenu local ou les textes fiscaux, qui distinguent expressément détention directe et indirecte - et le silence de l'article 71 bis ne saurait être converti en prohibition implicite de l'interposition.

En deuxième lieu, la ratio legis - faire bénéficier effectivement des personnes physiques congolaises de la richesse minière - est intégralement satisfaite par la coopérative, et mieux que par toute holding de droit commun : le lien commun statutaire (article 8 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives) réserve la qualité de membre aux seuls travailleurs congolais, personnes physiques par définition ; les parts, nominatives et non négociables (articles 45 et 49), ne peuvent circuler au profit de tiers ; la transparence économique est totale, chaque franc de dividende remontant nécessairement à des personnes physiques congolaises. Aucun risque de contournement par des non-nationaux n'existe donc - là où une détention directe, paradoxalement, laisserait les titres circuler au gré des cessions individuelles et des successions.

En troisième lieu, l'effet utile : imposer l'inscription individuelle de centaines ou de milliers de travailleurs au registre des titres rendrait l'obligation pratiquement inexécutable et la tenue des assemblées impraticable ; on ne peut prêter au législateur minier l'intention d'avoir édicté une règle inapplicable.

En dernier lieu, l'administration s'oriente elle-même vers cette lecture : le projet de décret d'application de l'article 71 bis envisage précisément la détention collective des 5 % des travailleurs par la voie de coopératives. Il serait pour le moins paradoxal que soit sanctionné un schéma que le pouvoir réglementaire s'apprête à consacrer.⁹

L'article 144 bis prévoit que ces parts sont librement cessibles. Pris à la lettre, il permettrait même leur cession à des personnes qui ne sont pas congolaises. Cette possibilité confirme l'intérêt d'un mécanisme de détention collective. En effet, si les salariés détenaient leurs parts à titre individuel, ils pourraient être amenés à les vendre rapidement à des intermédiaires ou à des investisseurs, ce qui finirait par faire disparaître la participation congolaise que la loi cherche précisément à préserver¹⁰.

13.

Le risque résiduel d'une lecture formaliste ne doit pas pour autant être ignoré ; il se couvre par trois précautions cumulables.

- La première est documentaire : verrouiller la transparence statutaire de la coopérative - membres exclusivement travailleurs congolais personnes physiques, objet limité au portage des titres de l'employeur, dévolution fermée - et présenter le schéma, dans le dossier de conformité à déposer avant le 31 juillet 2026, comme une détention par des personnes physiques congolaises par l'intermédiaire d'un véhicule intégralement et exclusivement composé d'elles, en sollicitant du Ministère des mines une prise de position écrite.
- La deuxième précaution offre une voie littéralement conforme, si l'administration devait néanmoins se montrer formaliste : l'indivision organisée de l'article 127 de l'AUSCGIE. Les travailleurs sont inscrits au registre des titres comme copropriétaires indivis des 5 % - la détention est alors, à la lettre même du Code minier, le fait de personnes physiques de nationalité congolaise - mais ils sont représentés par un mandataire unique. La règle étant supplétive (« à défaut de clause contraire des statuts »), les statuts de la société minière peuvent confier ce mandat à la coopérative des travailleurs, qui redevient gestionnaire plutôt que propriétaire : le blocage de gouvernance est neutralisé, une seule voix s'exprimant en assemblée, sans rien sacrifier de la lettre du texte.

⁹ Selon les éléments rapportés par la presse spécialisée (not. Agence Ecofin, 24 juin 2026), le projet de décret d'application prévoit la détention collective des 5 % des travailleurs par le canal de coopératives, le financement de l'acquisition par des crédits sans intérêt consentis par l'entreprise et remboursés par prélèvement sur les dividendes, ainsi que l'interdiction de toute dilution de la participation congolaise.

¹⁰ Sur ce risque de voir les salariés se muer en « porteurs transitoires » de titres, voy. V. Mbombo Mudiangombe, op. cit.

- La troisième précaution, en variante, mobilise le démembrement de propriété : la nue-propriété des titres est inscrite au nom des travailleurs individuellement — la qualité d'actionnaire et la détention du capital demeurant ainsi attachées à des personnes physiques congolaises — tandis que l'usufruit ou un mandat de gestion est confié au véhicule collectif, qui centralise l'encaissement et la redistribution des dividendes. Dans les trois configurations, le couple « détention par les personnes physiques / gestion collective unifiée » est préservé ; seul varie le point d'ancrage de la propriété.

3. Le financement : la gratuité organisée par l'AUSCGIE plutôt que l'endettement des salariés

14.

Le blocage financier - des titres valorisés en dizaines, voire en centaines de millions de dollars - ne se résout pas d'abord par le crédit, mais par les mécanismes de gratuité que l'AUSCGIE organise lui-même :

- *Attribution gratuite d'actions (articles 626-1 à 626-6)* : l'assemblée générale extraordinaire peut attribuer gratuitement aux salariés jusqu'à 10 % du capital social - soit le double du quantum requis par le Code minier - au moyen d'actions existantes ou à émettre, le coût étant porté par la société (rachat préalable ou incorporation de réserves). Les périodes minimales d'acquisition et de conservation de deux ans constituent un *vesting* légal qui absorbe l'essentiel de la logique *good leaver / bad leaver* sans ingénierie contractuelle additionnelle ;
- *Rachat d'actions dédié (article 640)* : par dérogation à l'interdiction pour la société d'acquérir ses propres titres (article 639), la société qui fait participer ses salariés à ses résultats peut racheter ses propres actions en vue de les leur attribuer - la voie naturelle pour loger les 5 % à céder ;
- *Sur l'objection tirée du caractère « payant » de la participation* : l'article 71 bis exige que des personnes physiques de nationalité congolaise détiennent 10 % du capital ; il n'impose nulle part que le prix en soit décaissé par les salariés eux-mêmes, seule la participation de l'État étant expressément « libre de toutes charges » (article 71, *littera d*). Rien n'interdit donc que le coût de l'actionnariat salarié soit supporté par la société ou par son actionnaire majoritaire ; exiger au contraire un décaissement personnel des travailleurs réserverait au surplus, de facto, l'accès au capital aux salariés les mieux rémunérés, à rebours de la vocation inclusive du dispositif¹¹ ;

¹¹ V. Mbombo Mudiangombe, *op. cit.*

- À titre subsidiaire, l'augmentation de capital réservée : suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires nommément désignés (articles 586 et 587, les bénéficiaires ne prenant pas part au vote), à un prix calibré, complétée le cas échéant par un crédit de portage sans intérêt remboursable exclusivement par prélèvement sur les dividendes futurs (*vendor financing*) — schéma qui correspond du reste aux orientations du projet de décret d'application.

4. La valorisation : une catégorie d'actions de préférence « salariés » (art. 778-1 et suiv. AUSCGIE)

15.

L'objection récurrente de la survalorisation des titres trouve une réponse proprement sociétaire. Depuis la révision de 2014, il peut être créé des actions de préférence « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » (article 778-1). Rien ne s'oppose à ce que les 5 % des salariés soient logés dans une catégorie dédiée, assortie de droits financiers différenciés : dividende prioritaire ou majoré pour garantir un flux régulier, mais exclusion des droits sur les réserves et plus-values constituées antérieurement à l'émission. La valeur des droits attachés étant objectivement moindre, le prix de souscription peut être réduit d'autant, sans libéralité ni rupture d'égalité - dans la seule limite de la prohibition des clauses léonines (art. 54) - et peut en outre s'appuyer sur les valorisations certifiées publiées dans le cadre de l'ITIE-RDC.

L'émission au profit de bénéficiaires dénommés emprunte la procédure des avantages particuliers (article 778-10, renvoyant aux articles 619 à 625) : rapport d'un commissaire aux apports et vote de l'assemblée hors la participation des bénéficiaires, ce qui sécurise l'opération à l'égard des actionnaires minoritaires comme de l'administration ; la catégorie est ensuite protégée par l'assemblée spéciale de ses titulaires (article 555).

16.

Le schéma type qui se dégage - une coopérative de travailleurs détenant une catégorie d'actions de préférence acquise par attribution gratuite ou par rachat dédié - présente l'avantage décisif d'être intégralement documentable pour l'échéance du 31 juillet 2026 : statuts actualisés, registre des titres nominatifs, procès-verbaux d'assemblée et statuts coopératifs forment la preuve juridique exigée par la circulaire ministérielle. L'indivision organisée de l'article 127 de l'AUSCGIE demeure, au besoin, la voie de repli littéralement conforme au prescrit de l'article 71 bis.

17.

Reste, enfin, l'hypothèse-limite de la société qui, malgré une structuration engagée avec diligence, ne parviendrait pas à boucler son schéma dans le délai. La lettre de l'article 144 bis - qui vise « un ou plusieurs Congolais capables d'acquérir les parts ou actions sociales » - lui fournirait alors un ultime argument : le critère de capacité, qui renvoie tant à la capacité juridique qu'à la capacité financière des bénéficiaires, accrédite la lecture selon laquelle l'obligation s'analyse en une obligation de moyens renforcée, satisfaite dès lors que toutes les démarches raisonnables ont été entreprises¹². Cet argument doit toutefois être manié pour ce qu'il est : un moyen de défense d'ultime recours, non une voie de conformité. Il ne dispense pas d'exécuter - et sa force est inversement proportionnelle à l'inaction de celui qui l'invoque : dès lors que les mécanismes exposés ci-dessus permettent de constituer la participation sans même solliciter la capacité financière des bénéficiaires, l'opérateur qui n'aura rien structuré sera mal fondé à plaider l'impossibilité. C'est donc en complément du schéma et non à sa place - qu'il convient de documenter les diligences accomplies (offres faites aux salariés, appels à manifestation d'intérêt, procès-verbaux des organes sociaux) et de les verser au dossier de conformité, l'observation valant pour les 5 % des travailleurs comme pour les 5 % des investisseurs congolais visés au point III.

III. L'ACCES DES PERSONNES PHYSIQUES CONGOLAISES (5 %) AU CAPITAL – COMMENT PROCEDER EN PRATIQUE ?

18.

L'accès des investisseurs individuels congolais à 5 % du capital d'un projet minier majeur se heurte à un double obstacle : le déficit structurel de capitaux longs sur le marché local et l'exigence de stabilité de la quotité congolaise dans le temps. Plus encore que pour les salariés, la réponse doit être cherchée dans le droit des sociétés lui-même : plutôt que d'endetter l'investisseur congolais à hauteur d'une valeur qu'il ne peut porter, il s'agit de calibrer les titres qu'il souscrit. Cinq mécanismes, cumulables, peuvent être hiérarchisés du plus immédiat au plus progressif.

1. La décote objectivée par les actions de préférence (« *sweet equity* »)

19.

Le mécanisme décrit au point II.4 se transpose : une catégorie d'actions de préférence réservée aux investisseurs congolais, écartée des réserves antérieures et, le cas échéant, dotée d'un dividende « tracé » sur les flux de la mine en production, autorise une souscription à prix réduit avec des droits de vote pleins. L'investisseur congolais est ainsi un actionnaire

¹² La thèse de l'obligation de moyens renforcée, déduite du critère de capacité, est développée par V. Mbombo Mudiangombe, op. cit.

complet dès l'origine - et non le débiteur d'un crédit de portage - et la catégorie peut être rendue convertible en actions ordinaires (art. 778-6) à mesure que la valeur d'entrée est « rattrapée » par les distributions.

2. L'entrée progressive par valeurs mobilières composées (art. 822 et suiv. AUSCGIE)

20.

Depuis 2014, les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital : obligations convertibles ou remboursables en actions, bons de souscription autonomes. Souscrits pour un ticket initial modeste, ces titres organisent une montée au capital échelonnée, financée par les coupons et dividendes intermédiaires, sous la protection légale des porteurs (masse dotée de la personnalité juridique, ajustements anti-dilution, nullité des opérations de l'émetteur qui léseraient leurs droits). Ce mécanisme se combine avec une tranche d'actions souscrite immédiatement, seule la détention actuelle en capital satisfaisant la preuve de conformité attendue par l'administration.

3. Le démembrement temporaire de propriété (art. 128 AUSCGIE)

21.

Mécanisme parfois méconnu, le démembrement offre une décote sans crédit : l'investisseur congolais acquiert immédiatement la nue-propriété des 5 %, dont la valeur est structurellement réduite par l'usufruit temporaire (dix à quinze ans, par exemple) conservé par le cédant, et la pleine propriété se reconstitue automatiquement au terme, sans nouveau prix ni transfert. En droit OHADA, la règle supplétive de l'article 128 confère au nu-propriétaire le droit de vote pour toutes les décisions, l'usufruitier ne votant que l'affectation des bénéfices : la qualité d'actionnaire demeurant attachée à la nue-propriété, l'investisseur congolais exerce les droits politiques dès le premier jour, le texte autorisant du reste expressément une clause statutaire contraire si les parties souhaitent une autre répartition.

4. La syndication verrouillée : une SAS d'investisseurs à « congolité » statutaire

22.

La mutualisation de plusieurs dizaines d'investisseurs congolais - y compris de la diaspora, dont l'Ordonnance-loi n° 22/030 du 8 septembre 2022 encourage la mobilisation par le financement participatif - gagne à être organisée en SAS de droit congolais, dont la liberté statutaire (art. 853-1 et suiv.) permet de garantir dans la durée le caractère congolais du tour

de table : agrément de toute cession, même entre associés (article 853-18) ; exclusion statutaire avec cession forcée (art. 853-19); surtout, obligation pour tout associé personne morale d'informer la société de tout changement de son contrôle, sous peine de suspension des droits non pécuniaires et d'exclusion (art. 853-20). La «congolité» du véhicule cesse ainsi d'être déclarative pour devenir une condition statutaire dont la violation est sanctionnée par la nullité des cessions contraires (art. 853-19-1).

La même forme sociale permet de corriger une impasse fréquente : si l'apport en industrie est interdit dans la société anonyme (article 50-1 AUSCGIE), il est expressément admis dans la SAS (article 853-5), dans les limites de l'article 50-3 (25 % au plus des droits de vote et des bénéfices). Les apports immatériels d'un partenaire congolais — droits fonciers négociés, infrastructures d'accès, réseau commercial — peuvent ainsi être rémunérés en titres au niveau du véhicule de syndication, sans décaissement immédiat.

Le financement d'appoint demeure naturellement possible - crédit de portage remboursé par prélèvement sur les dividendes, nantissement des titres, promesses croisées d'achat à prix plancher dont la validité est admise, par transposition de la jurisprudence Bowater¹³, dès lors qu'elles portent sur la cession des titres et demeurent étrangères au pacte social (art. 54) - sous une réserve essentielle : la détention congolaise doit rester effective. Un portage qui laisserait la propriété réelle des titres entre les mains de l'opérateur étranger s'exposerait à la requalification en fraude à l'article 71 bis.

5. La non-dilution organisée statutairement

23.

Enfin, à l'image des parts non diluables de l'État, la quotité congolaise de 10 % peut être immunisée contre les opérations futures sur le capital par une stipulation statutaire de maintien de quotité : attribution, lors de toute augmentation de capital, d'actions nouvelles ou de bons de souscription au profit des véhicules congolais à proportion de leur participation, selon un mécanisme de ratchet emprunté à la pratique du capital-investissement. Cette clause anticipe l'interdiction de dilution envisagée par le projet de décret d'application et évite que la conformité acquise en 2026 ne soit défaite par la première recapitalisation venue.

¹³ Cass. com. (fr.), 20 mai 1986, Bowater ; solution constamment réaffirmée depuis (not. Cass. com., 16 novembre 2004 ; 22 février 2005). Sur sa transposition en droit OHADA : S. Diagne Ndir, « Portage d'actions et clauses léonines en droit OHADA », ohada.com, juin 2018.

IV. CONCLUSION

24.

Les discussions en cours au sein de la Chambre des mines de la Fédération des Entreprises du Congo témoignent de réserves techniques compréhensibles : survalorisation des titres au regard de la capacité financière des travailleurs et des investisseurs congolais, absence supposée de véhicule adapté en droit positif, crainte d'une gouvernance paralysée par un actionnariat diffus. La présente analyse démontre que ces objections, réelles, ont chacune leur réponse en droit positif — et qu'il n'est besoin pour cela ni d'un trust étranger à notre ordre juridique, ni d'un assouplissement législatif hypothétique.

Le droit OHADA fournit l'intégralité de l'outillage : la société coopérative offre le véhicule collectif à capital variable que l'on croyait manquer ; l'attribution gratuite d'actions et le rachat dédié organisent la gratuité que la capacité contributive des salariés impose ; les actions de préférence permettent de calibrer objectivement la valeur d'entrée ; l'indivision organisée et le démembrement de propriété garantissent, au besoin, une conformité à la lettre même de l'article 71 bis ; et la liberté statutaire de la SAS verrouille dans la durée le caractère congolais des véhicules d'investisseurs. Ces mécanismes convergent du reste avec les orientations annoncées du projet de décret d'application — de sorte que l'opérateur qui structure sa conformité dès à présent anticipe la réglementation à venir plutôt qu'il ne la subit.

25.

L'échéance du 31 juillet 2026 ne doit donc pas être abordée comme une menace, mais comme l'occasion d'une mise en ordre que le droit des sociétés permet d'exécuter sans dénaturer l'économie des projets : la preuve de conformité exigée par l'autorité de tutelle - statuts, registres des titres, procès-verbaux, pactes - est intégralement constructible avec les instruments décrits ci-dessus. Une ingénierie juridique rigoureuse est ainsi le meilleur garant, tout à la fois, de la sécurité des titres miniers, de la protection des investissements étrangers et de la paix sociale avec des travailleurs qui n'exigent, au fond, que l'application effective de la loi.

Kinshasa, juillet 2026